

# 통상임금 판결의 고정성 요건 삭제의 향후 영향

○ 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 및 2023다302838

전원합의체 판결

양 승 엽(한국노동연구원 부연구위원)

## [판결요지]

고정성이란 잣대 없이도, 근로자와 사용자가 소정근로시간에 제공하기로 정한 근로의 대가라는 ‘소정근로 대가성’, 임금의 지급 시기와 지급 대상이 미리 일정하게 정해졌을 것을 요구하는 ‘정기성’과 ‘일률성’의 개념을 통하여 통상임금에 해당하는지 여부를 올바르게 판단할 수 있다(2020다247190 판결).

통상임금이 연장근로수당과 같은 법정수당 산정을 위한 도구개념인 점을 고려하면 ‘사전적 산정 가능성’이 확보되어야 한다는 요청도 중요하게 고려하여야 한다. 즉, 통상임금 판단 기준은 명확하고 예측가능성이 있는 것이어야 한다(2023다302838 판결).

## 1. 사실관계 및 소송의 경과<sup>1)</sup>

2020다247190 판결의 사안을 보면, ‘재직 조건 임금’ 사건으로 피고 소속 근로자로 재직 중이거나 퇴직한 원고들은 지급일 기준 재직자에게 지급하는 재직 조건부 정기상여금과 성과급의 최소 지급분은 통상임금에 해당한다고 주장하면서 법정 통상임금을 새롭게 계산하여 상응한 시간 외 근무수당의 차액을 청구하였다. 2023다302838 판결의 사안은 ‘근

1) 양 사건의 사실관계와 하급심의 판결 요지는 2024. 12. 19. 대법원의 보도 자료 「대법원 2020다247190 임금 사건, 대법원 2023다302838 임금 사건」의 내용을 인용하여 소개함.

무일수 조건 임금’ 사건으로 피고 소속 근로자인 원고들은 기준 기간 내 15일 미만으로 근무한 경우 지급 대상에서 제외되는 정기상여금은 그 조건 성취와 관계없이 통상임금에 포함된다고 주장하면서, 이를 통상임금에 넣어 재산정한 연장근로수당 등의 차액을 청구하였다.

2020다247190 판결의 제1심은 기존 대법원의 통상임금 전원합의체 판결의<sup>2)</sup> 판시에 따라 고정성 탈락을 이유로 재직 조건부 정기상여금의 통상임금성을 부정하였으나, 성과급 최소 지급분의 통상임금성은 긍정하였다. 그러나 원심은 고정성 요건을 그대로 인정하되 사실관계의 판단을 달리하여 재직 조건의 유효성을 인정하기 힘들고 정기상여금에 고정성 요건을 인정하여 재직 조건부 정기상여금의 통상임금성을 긍정하였다. 그리고 성과급의 최소 지급분의 통상임금성 역시 인용하였다.

2023다302838 판결의 제1심과 원심은 기준 기간 중 15일 이상 근무하여야 한다는 근무일수 조건이 부가되는 정기상여금은 그 조건 성취 여부가 불확실하므로 고정성이 없다고 판단하여 해당 정기상여금의 통상임금성을 부정하였다.

## 2. 쟁점 및 대법원 주요 판시 내용

과거 대법원이 2013. 12. 18. 선고한 2012다89399 전원합의체 판결(이하 ‘2013년 통상임금 전합체 판결’이라 함)은 어떠한 임금이 통상임금이 되기 위해서는 정기성, 일률성, 그리고 고정성이라는 3가지 요건을 충족하여야 한다고 판시하였다. 세 요건 중 정기성과 일률성은 비교적 개념과 판단 여부가 쉬운 편이었지만, 고정성 개념은 이해가 힘들고 무엇보다 통상임금을 정의한 「근로기준법」 시행령 제6조 제1항에서 정기성과 일률성은 요건으로서 명문으로 규정하고 있으나, 고정성은 아무런 문구가 없어 통상임금의 범위를 부당하게 좁히고 있다는 비판을 받고 있었다.

2013년 통상임금 전합체 판결은 ‘고정성’에 대해서 다음과 같이 설명한다. “고정성을 갖춘 임금은 근로자가 임의의 날에 소정근로를 제공하면 추가적인 조건의 충족 여부와 관계없이 당연히 지급될 것이 예정된

2) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

임금이므로, 그 지급 여부나 지급액이 사전에 확정된 것”이라 할 수 있다. “이와 달리 근로자가 소정근로를 제공하더라도 추가적인 조건을 충족하여야 지급되는 임금이나 그 조건 충족 여부에 따라 지급액이 변동되는 임금 부분은 고정성을 갖춘 것이라고 할 수 없다”라고 한다. 여기서 고정성 요건의 몇 가지 키워드를 골라보면 “예정된”, “사전 확정”, 그리고 “무조건” 등을 생각해 볼 수 있다. 즉, 조건이 없어 임금 지급 전에 얼마를 주어야 하는지 알 수 있는 것이 정해진 임금이 ‘고정된’ 임금이라는 것이다. 따라서 재직 여부나 일정 이상의 근무일수가 조건으로 걸리거나, 근무실적 평가를 토대로 지급액이 결정되는 임금은 조건이 걸려 사전 확정이 되지 않기 때문에 고정성이 탈락되는 것이다.

이번 통상임금 전원합의체 판결은 종전 판례가 실시한 고정성 개념을 통상임금의 주요 요건으로 계속 유지할 것인가가 쟁점이 되었다. 그리고 만일 고정성 요건을 삭제한다면 통상임금의 개념을 어떻게 구성할 것인가도 문제가 되었다.

대법원은 2020다247190 판결 및 2023다302838 판결에서 통상임금이 가져야 할 성격을 ①법령 부합성, ②강행성, ③소정근로 가치 반영성, ④사전적 산정 가능성, ⑤정책 부합성으로 나누고 통상임금이 ‘고정성’ 개념을 유지하는 한 이러한 다섯 가지의 성격을 가질 수 없다는 것을 논증하였다. 즉, 통상임금은 법적 개념이자 강행적 개념이어서 법령의 정의에 충실하면서도 당사자가 이를 임의로 변경할 수 없어야 하는데, 고정성은 법문에 규정이 없고 조건을 설정함으로써 임의로 변경할 수 있어 ①과 ②의 요건에 부합하지 않는다는 것이다. 그리고 통상임금은 ‘소정’근로의 가치를 평가한 개념으로 실근로와 무관하게 그 자체의 가치를 온전하게 반영하여야 하는데, 조건을 달아 고정성을 요구하면 실근로와 연결되기 때문에 ③을 충족하지 못한다. 또한, 고정성의 역할로 통상임금이 가지는 예측가능성이 유지되었지만, 고정성 없이도 ‘사전적 산정 가능성’이란 개념으로 그 기능을 보완할 수 있고, 임금에 조건을 설정하면 “사후적 변동가능성이 있는 실근로를 통상임금과 연계하게” 되어 “통상임금의 사전적 산정 가능성이 약화”된다고 한다. 이로써 조건부라는 고정성은 ④요건에 부합할 수 없다. 마지막으로 고정성이란 요건으로

통상임금의 범위를 좁히는 것은 연장·야간·휴일근로를 억제하려는 근로기준법의 정책에 들어맞을 수가 없어 ⑤에도 적합하지 않다.

이러한 이유로 두 대법원 전원합의체 판결은 고정성을 제외하고 정기성과 일률성을 바탕으로 한 통상임금의 개념을 새롭게 정립하여 “근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당한다”라고 한다.

이러한 판시를 바탕으로 그동안의 판례 법리를 변경하여 고정성을 이유로 통상임금성을 부정해 온 재직조건부 임금과 근무일수 조건부 임금의 통상임금성을 인정하였고, 순수히 근무실적만으로 지급되는 성과급은 여전히 통상임금성이 부정되지만, 그것과는 관계없이 지급되는 성과급의 최소 지급분은 소정근로의 대가로 통상임금성을 긍정하였다.

### 3. 고정성 요건의 삭제와 향후 해석의 방향

이렇듯 이번 통상임금 전원합의체 판결이 통상임금의 고정성 요건을 삭제함으로써 통상임금의 범위가 넓어진 것은 법리적으로 사실이다. 그러나 실제 사업장에서 통상임금에 대한 해석 다툼이 사라져 분쟁이 줄어들까에 대해서는 다소 회의적인 생각이 든다. 왜냐하면 앞서 설명한 바와 같이 고정성의 키워드인 ‘조건부’와 ‘사전 확정(또는 예정)’은 사라졌지만, 대법원이 그것을 대체할 ‘사전적 산정 가능성’을 제시함으로써 여전히 많은 해석의 여지를 남겨놓은 것이다. 2023다302838 판결에서 대법원은 “통상임금이 연장근로수당과 같은 법정수당 산정을 위한 도구 개념인 점을 고려하면 ‘사전적 산정 가능성’이 확보되어야 한다는 요청도 중요하게 고려하여야 한다. 즉, 통상임금 판단 기준은 명확하고 예측 가능성이 있는 것이어야 한다”라고 판시한다. 또 다르게는 “사전 확정성은 애당초 완벽하게 달성할 수 없는 지표이기도 하다”라고 하며 사전 확정성이란 것을 통상임금 판단의 잣대로 삼을 수 없다고 판시하지만, 동시에 ‘사전적 산정 가능성’의 확보를 요구하고 있다. 양자를 비교하면, ‘사전’은 같고 ‘확정성’과 ‘산정 가능성’이 다른데, 무엇이 확고하게 있어

달라질 가능성 자체가 없다는 ‘확정성’과 변경될 수도 있다는 ‘산정 가능성’은 그 의미가 구분된다고 할 수 있다. 그러나 개념으로야 분리되지만, 실무적으로 어떤 임금 항목에 있어 양자를 뚜렷히 구분할 수 있을지가 의문이다. 가령 어떤 임금 항목에 조건을 달고 새롭게 이것이 ‘사전적 산정 가능성’을 예측할 수 없어 통상임금성이 부정된다고 주장할 수 있는 것이다.

도식화한다면 과거 2013년 통상임금 전합체 판결의 고정성 개념은 ‘무조건부’ + ‘사전 확정성’이었다. 그런데 현재의 통상임금 전합체 판결은 여기에 ‘무조건부’를 떼었지만 ‘사전적 산정 가능성’이라는 ‘사전 확정성’보다 범위는 넓지만 더욱 모호한 개념으로 대체함으로써 해석의 여지를 더 넓혔다. 실무적으로 통상임금의 범위를 좁히고 싶은 사용자 입장에서는 여전히 임금 항목에 조건을 달고 이것을 사전적 산정 가능성의 영역으로 넘겨 다투고자 할 것이다. 고정성을 부정하는 핵심 키워드였던 조건부를 뺐지만, 조건부가 ‘사전적 산정 가능성’이란 요건과 결합하여 해석의 여지를 남긴다면 고정성 요건을 삭제한 의의가 사라진다. 물론 사법부가 ‘사전적 산정 가능성’을 ‘소정 근로’의 대가, 즉 당사자가 사전에 근로의 대가로 지급하기로 합의한 금액이라고 엄격히 해석할 수도 있을 것이다. 그러나 굳이 소정 근로의 대가라는 개념적 정의로 좁게 군힐 수 있는 영역을 ‘사전적 산정 가능성’이란 명문으로 해석의 길을 열어 놓은 이상, 다시 ‘사전’과 ‘산정 가능’이라는 해석에 매달리게 될 수도 있어 우려가 남는다.